

1501169-23.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Denise Gomes Bezerra Mota

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/09/2022

... condenação recente e definitiva pelo crime de tráfico de drogas, fls. 73/74 - eventual progressão de regime será apreciada necessariamente pelo juízo da execução. Destaco que as alterações trazidas pela Lei nº 12.736/2012, que acrescentou o parágrafo 2º ao artigo 387 do Código de Processo Penal, não revogaram os dispositivos da Lei de Execução Penal, que devem também ser considerados ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

1ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11440-550

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501169-23.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501169-23.2022.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em

Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2083259/2022 - DEL.INV.GER. SANTOS, 95/2022 -

DEL.INV.GER. SANTOS, 2083259 - DEL.INV.GER. SANTOS, 95/22/201 - DEL.INV.GER. SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVID DOS SANTOS MACHADO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Denise Gomes Bezerra Mota

Vistos.

David dos Santos Machado, Igor Gonçalves de Abreu de Jesus e Cleverson Nascimento de Almeida Júnior, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, no dia 25 de março de 2022, por volta das 15:15 horas, na Rua Valter Papsch, altura do nº 50, Jardim Virgínia, nesta cidade e comarca de Guarujá-SP, em conluio e unidade de desígnios entre si e com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida por meio de um simulacro de arma de fogo, tentaram subtrair, para proveito comum, bens de propriedade da vítima protegida, nos termos do Provimento CG nº 32/00, somente não consumando o delito por razões alheias às suas vontades.

Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, David dos Santos Machado trazia consigo, para consumo pessoal, sem autorização e em

desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma porção de maconha, conforme laudo de exame-químico toxicológico de fls. 194/196.

Recebida a denúncia (fls. 154/155), os réus foram citados (fls. 184, 186, 188) e apresentaram respostas à acusação (fls. 160/165, 205/207, 208/209), que não comportaram acolhimento (fls. 215/217).

Durante a instrução do feito, foram ouvidas a vítima, cinco testemunhas e o réus foram interrogados (fls. 388). Encerrada a instrução, pelas partes não foram requeridas diligências, nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal (fls. 386).

Nos memoriais, a representante do Ministério Público requereu a procedência da ação, por entender que a materialidade e a autoria dos delitos restaram comprovadas nos autos (fls. 392/398).

A defesa do réu David, nos memoriais, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão espontânea e a concessão ao réu do direito de apelar em liberdade (fls. 405/407).

A defesa do réu Igor, nos memoriais, requereu a improcedência da ação para absolver o réu, nos termos do artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal, pois se trata de crime impossível, nos termos do artigo 17 do Código Penal, considerando que o acompanhamento do desenrolar dos fatos desde o início, pelos agentes policiais, torna ineficaz qualquer tentativa de êxito delitivo, tratando-se de flagrante preparado. Subsidiariamente, requereu a absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, pela fragilidade do conjunto probatório. Em caso de entendimento diverso, pugnou pela desclassificação para o crime de furto qualificado tentado, com a redução em seu patamar máximo, bem como pela fixação da pena-base no mínimo legal, pela fixação do regime inicial aberto e, subsidiariamente, do semiaberto, verificando-se a detração, e pela concessão ao réu do direito de apelar em liberdade (fls. 421/436).

A defesa do réu Cleverson, nos memoriais, requereu preliminarmente a declaração de nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede inquisitorial e, por conseguinte, de todos os demais atos que o sucederam. Em caso de entendimento diverso, no mérito, requereu a improcedência da ação nos termos do artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal, pois o delito se encontrava em fase de atos preparatórios, que são impuníveis. Subsidiariamente, requereu a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal, reconhecendo-se o crime impossível, nos termos do artigo 17 do Código Penal, porquanto o flagrante foi preparado pela Polícia Civil, que agiu sem autorização judicial.

Subsidiariamente, requereu a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo, pela fragilidade do conjunto probatório. Permanecendo diverso o entendimento, pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal, pela aplicação da causa de aumento do concurso de agentes em 1/3, pelo reconhecimento da tentativa em seu patamar máximo, pela fixação do regime inicial aberto - observando-se a detração - pela concessão ao réu do direito de apelar em liberdade (fls. 438/455). É o relatório.

Decido.

A preliminar de nulidade suscitada pela defesa do réu Cleverson não merece acolhimento.

Não há qualquer nulidade no reconhecimento realizado pela vítima em sede inquisitorial, por suposta violação ao disposto no artigo 226 e nos seguintes, do Código de Processo Penal, sob a alegação de que os acusados não foram colocados ao lado de indivíduos com características semelhantes.

Ora, cabe lembrar que tal requisito de procedimento é restrito à possibilidade de seu preenchimento, razão pela qual é prescindível. E, além de prescindível a observância de tal requisito, sua ausência não macula a segurança do reconhecimento, especialmente "in casu", considerando que a vítima reconheceu os acusados com clareza e sem sombra de dúvidas, logo após a ocorrência dos fatos, como sendo os autores da tentativa de roubo de seus bens (fls. 06/07).

Portanto, no caso dos autos, não há qualquer irregularidade no reconhecimento pessoal realizado na fase extrajudicial pela vítima. Ademais, eventual nulidade do inquérito não repercute sobre o processo, mesmo que o reconhecimento pessoal fosse

nulo, seria invalidada apenas essa prova e não o processo.

Nesse sentido, a jurisprudência:

"[...] as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso" (STJ - AgRg no AREsp 1376249/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019).

Assim, não comprovada qualquer circunstância que torne suspeita a identificação dos réus, resta afastada a preliminar suscitada pela defesa.

Ainda, não merece guarida a tese de absolvição dos acusados pelo reconhecimento da figura do flagrante preparado, que é ilegal e caracteriza o crime impossível, pois impede o resultado lesivo. No flagrante preparado, o agente é induzido à prática do crime por aquele que pretende o flagrante. Por sua vez, o flagrante esperado não é ilegal, e caracteriza-se quando aquele que pretende o flagrante tão somente aguarda a prática do crime, sem induzir o agente a praticá-lo. No caso em apreço, resta evidente que não se trata de flagrante preparado, considerando que os acusados não foram induzidos à prática delituosa. A vítima tão somente atendeu ao pedido "do cliente" e agendou data e horário para orçamento da prestação de seus serviços de gesseiro, comunicando tal fato à Polícia, por temor e desconfiança de que se tratasse de crime em fase preparatória.

Desta forma, não se pode pretender a absolvição dos réus Cleverson e Igor pela excludente de tipicidade do crime impossível, porquanto o monitoramento dos acusados pela equipe policial não tornou impossível a prática do crime.

Ressalte-se, ainda, que as provas dos autos revelam que os policiais civis permaneceram em campana nos arredores do local dos fatos e apenas agiram quando os réus deram início à execução do roubo, cumprindo, então, com a obrigação de impedi-los. Tal situação não configura, evidentemente, flagrante preparado, tampouco crime impossível - o que também vem a afastar a tese da defesa de Cleverson de que o delito estava em fase de atos preparatórios, que são impuníveis e caracterizaria a atipicidade da conduta.

E de igual modo a idoneidade do meio utilizado para intimidar a vítima - um simulacro de arma de fogo - também afasta a tese do crime impossível, pois um simulacro pode intimidar e retirar a possibilidade de resistência da vítima de roubo de forma tão eficaz como uma arma verdadeira.

A propósito:

"Apelação criminal. Crime contra o patrimônio. Roubo majorado. Crime impossível inócurrenente. [...] Não se cogita, na espécie, de crime impossível, pois evidente que a presença de policial militar nas proximidades do local dos fatos não torna inidônea a tentativa, sendo plenamente possível que o delito se consume. [...] A condenação de todos os acusados pelos cinco crimes de roubo era mesmo de rigor, não havendo que se falar em absolvição em nenhuma de suas modalidades [...]" (TJ-SP - APR: 15015943120198260544/SP, Relator: Fábio Gouvêa, Data de Julgamento: 27/08/2020, 10ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/08/2020)

Ainda, nesse sentido:

"Apelação criminal. Crime contra o patrimônio. Roubo Majorado. [...] Condenação mantida. Flagrante preparado incabível. Crime impossível inócurrenente.

[...] Tentativa cabível. [...] As provas revelam que os policiais civis permaneceram em campana nos arredores do estabelecimento comercial vítima, observando a movimentação, e apenas agiram quando os apelantes deram início à prática do roubo, cumprindo com o dever de impedi-lo, situação que não configura flagrante preparado e tampouco crime impossível. Suficiência probatória. Existem provas suficientes da ocorrência dos fatos e do envolvimento dos três réus no roubo descrito na denúncia. Caso em que interceptações telefônicas captaram conversas de dois réus combinando o roubo. Os policiais civis fizeram campana nos arredores do estabelecimento vítima e detiveram os réus em flagrante no momento em que estavam executando o roubo. Condenação mantida. [...] Tentativa cabível. No momento em que os policiais surpreenderam os assaltantes, o roubo estava em andamento, pois deram ordem voz de prisão ao apelante no instante em que ele estava se preparando para roubar o dinheiro do estabelecimento, de modo que resta configurada a tentativa

[...]. Preliminares de nulidades rejeitadas. V.U.[...]." (TJ-RS - APL.: 70067901140 RS, Relator: Ícaro Carvalho de Bem Osório, Data de Julgamento: 04/02/2016, Sexta Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/03/2016). Portanto, o processo está em ordem, restando afastadas as preliminares arguidas. Passo à análise do mérito.

No mérito, a ação é procedente.

Com efeito, a materialidade do delito de roubo, em concurso de pessoas, bem como a materialidade do delito de trazer consigo droga para consumo pessoal (réu David), estão demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 26/31), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 32/33), pelo laudo de exame-químico toxicológico (fls. 194/196), pelo laudo pericial do simulacro de arma de fogo (fls. 368/371), bem como pela prova oral coligida nos autos. A autoria dos réus também restou incontroversa pelas provas produzidas durante a instrução criminal.

Em seu interrogatório, na fase extrajudicial, o acusado David exerceu o direito de permanecer em silêncio (fls. 20).

Interrogado em juízo, o acusado David confessou a autoria dos delitos de roubo e de porte de droga para consumo pessoal. Relatou que, na data dos fatos, recebeu o pedido de um rapaz para pegar um uber e buscar uma "fita" com determinada pessoa que estaria em uma Saveiro branca. No trajeto, quando o carro parou na frente de um supermercado, o interrogando avistou Igor no ponto de ônibus e perguntou para onde ele iria, e ele disse que estava indo para sua academia dar aula. Ofereceu carona para Igor e um colega de Igor, Cleverson. O interrogando portava um simulacro de arma de fogo, na data dos fatos, que comprou na Aparecida do Norte há muito tempo. Cleverson iria ajudar Igor na limpeza da academia, por tal motivo o interrogando ofereceu carona aos dois. Afirmou que ao descerem do uber, Igor e Cleverson não fizeram cerco à vítima. Somente o interrogando se aproximou da vítima para abordá-la. Igor e Cleverson não sabiam o que o interrogando iria fazer no local. De repente, os policiais se apresentaram efetuando dois disparos, e Igor saiu correndo, muito assustado. O interrogando desconhece quem é a pessoa que lhe telefonou pedindo para ele cometer o roubo. Havia uma pessoa em um carro preto aguardando o interrogando, o carro da vítima não seria levado embora. O interrogando levaria consigo apenas o dinheiro. Arrepende-se de sua conduta (fls. 388).

Em seu interrogatório, na fase extrajudicial, o acusado Igor exerceu o direito de permanecer em silêncio (fls. 21).

Interrogado em juízo, o acusado Igor negou a autoria delitiva. Relatou que ministra aulas de artes marciais, e que sua academia é perto da pizzaria Papa-Léguas, na Vila Rã. Na data dos fatos, foi à casa de Cleverson chamá-lo para treinar. Encontraram-se na portaria e ficaram em frente ao supermercado Roldão, no ponto de ônibus. David passou por lá de uber e perguntou se o interrogando queria uma carona, e este aceitou, porque teria que faxinar a academia e assim chegaria mais cedo. Cleverson foi junto no uber. Quando chegaram em certo local e desceram do carro, foram surpreendidos por um carro descaracterizado cujo ocupante começou a atirar para cima e o interrogando, com medo, saiu correndo. Assim que foi alcançado e as pessoas se identificaram como policiais, o interrogando não ofereceu resistência e se deitou no chão. A academia onde o interrogando trabalha é na Av. Paumar, Vila Rã, é próxima do local dos fatos (fls. 388).

Em seu interrogatório, na fase extrajudicial, o acusado Cleverson exerceu o direito de permanecer em silêncio (fls. 22).

Interrogado em juízo, Cleverson negou a autoria delitiva. Relatou que tudo o que estão lhe imputando é mentira. Na data dos fatos, foi ajudar o réu Igor a fazer uma faxina na academia, e havia sido chamado no dia anterior. Encontravam-se no ponto do supermercado Roldão, aguardando o ônibus, quando o réu David passou em um carro vermelho e ofereceu uma carona a Igor para a Enseada. Quando pararam no local dos fatos, desceram do uber e começaram a andar, momento em que parou um carro preto dando tiro para o alto e anunciando que era a Polícia. O réu Igor se assustou e correu. Não conhece o réu David. Na data dos fatos só aceitou a carona com David

porque se encontrava com o réu Igor e este aceitou a carona. Após ajudar Igor na limpeza da academia, iria treinar com Igor nesse dia, na comunidade Conceiçãozinha (fls. 388).

Entretanto, não obstante a negativa de autoria dos réus Igor e Cleverson, as provas dos autos, produzidas sob o crivo do contraditório, demonstraram a autoria delitiva dos três réus e não foi apresentada situação capaz de excluir o crime ou isentá-los de pena.

Senão vejamos.

Em juízo, a vítima protegida, nos termos do Provimento CG nº 32/00, declarou que recebeu ligação telefônica de um "cliente" solicitando o orçamento em uma obra. No dia e no horário combinados, o declarante foi à obra para fazer o orçamento da prestação de seus serviços de gesso. No local dos fatos, enquanto aguardava o cliente, três indivíduos chegaram de carro, desceram e se aproximaram do declarante, cercando o carro do declarante; momento em que anunciaram o roubo, mostrando-lhe uma arma de fogo. Quando um dos indivíduos apontou-lhe a arma, a Polícia, que estava no local dos fatos, interveio em seu favor e prendeu dois dos autores da tentativa de roubo. Um deles correu e foi alcançado logo em seguida. Os indivíduos não estavam com o rosto coberto. Tem lembrança de que um dos autores da tentativa de roubo exibia tatuagem na perna e outro talvez no pescoço. Em sede policial, fez o reconhecimento dos três indivíduos logo após os fatos, com segurança e sem sombra de dúvidas. Nada foi subtraído da vítima. Um comerciante conhecido do declarante, dias atrás, passou por algo parecido, e foi levado para um cativado e obrigado a fazer transferência de dinheiro por Pix, aos criminosos. Reafirmou que a Polícia estava no local dos fatos e impediu a consumação do roubo. Antes de realizar o reconhecimento na delegacia, informou à autoridade policial as características dos autores da tentativa de roubo. Em juízo, reconheceu com certeza somente o réu David (fls. 388).

Com efeito, a vítima é sempre pessoa categorizada a reconhecer o agente, pois sofre o traumatismo da ameaça ou da violência e não se propõe a acusar inocente, senão procura contribuir - como regra - para a realização do justo concreto.

De ressaltar-se, que, em sede de prova, nos crimes contra o patrimônio, como o roubo, crucial a palavra do ofendido, desde que coerente e segura, sendo a mais valiosa peça de convicção judicial. Ademais, é certo que os delitos de roubo, em regra, são cometidos na clandestinidade, sendo a palavra da vítima de suma importância para o esclarecimento dos fatos.

Neste sentido, a jurisprudência:

"[...] nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios [...]". (STJ, AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, j. 09/03/2017, DJe 17/03/2017) " [...] nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer, se em consonância com as demais provas dos autos, como na hipótese em tela [...]". (STJ, HC 461477 / PE, 6ª Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 16/10/2018, DJe. 05/11/2018)

E as declarações da vítima não são provas isoladas nos autos, uma vez que corroboradas pelos depoimentos dos policiais civis que prenderam os acusados, na data dos fatos.

O policial civil Marcel Alexandre da Costa Rosa, em seu depoimento judicial, relatou que na data dos fatos estava dando apoio a seu colega Jairo na investigação de uma quadrilha que estava praticando crimes envolvendo transferência de dinheiro por Pix. O modus operandi da quadrilha consistia em contatar prestadores de serviço para fazerem orçamentos em obras; quando o prestador de serviços chegava ao local combinado, era mantido em cárcere e obrigado a transferir dinheiro de sua conta para a indicada pelos criminosos, na modalidade de pagamento eletrônico instantâneo Pix. A Polícia recebeu a informação de que o crime tratado nestes autos poderia ocorrer, então os policiais foram até o local em que o "cliente" teria combinado com o prestador de serviços. Na data dos fatos, o prestador de serviços chegou e na

sequência três rapazes chegaram em um Gol vermelho, que deixou os três indivíduos e seguiu seu destino. Os três acusados foram direto ao encontro da vítima, e quando iniciaram a execução do crime - um deles fazendo os movimentos característicos para sacar uma arma das costas - resolveram intervir para impedir a consumação do crime e abordaram os autores do fato. Um deles correu e foi alcançado poucos metros adiante. O que estava com a "arma", imediatamente já foi dizendo que se tratava de simulacro. O motorista do Gol vermelho era motorista de aplicativo de transporte privado, da empresa Uber, segundo os acusados. Um dos indivíduos chorou afirmando que não sabia de nada, que era professor de artes marciais e que estava lá para buscar um carro. Na foto de fl. 06, o depoente reconheceu o acusado de nº 1 (David) como sendo o que portava o simulacro, e na foto de nº 3 (Igor) o lutador de artes marciais (fls. 388).

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial civil Jairo da Silva Paula. A testemunha relatou que na data dos fatos foi procurado pela vítima protegida que narrou ter recebido a ligação de um "cliente", o qual solicitou orçamento de sua empresa para a prestação de serviços de colocação de gesso, informando o endereço da obra. A vítima protegida estava com receio de que pudesse ser um golpe para atraí-la, pois um amigo seu, gesseiro também, contou que alguém havia ligado para a empresa dele buscando um orçamento e dando o endereço da obra. E assim que o amigo chegou no endereço informado foi vítima de roubo. O telefone utilizado pelos indivíduos para contatar o amigo gesseiro da vítima protegida era o mesmo utilizado para o agendamento de orçamento com a vítima protegida, e o "cliente" insistia que o orçamento deveria ser feito pelo proprietário da empresa. A vítima protegida marcou data e horário e informou ao depoente, que montou uma equipe para a diligência e se deslocaram para o local dos fatos, descaracterizados. Um Gol vermelho se aproximou e dele desceram três indivíduos, que foram ao encontro da vítima protegida e iniciaram a execução do crime. Nesse momento, intervieram para evitar a consumação do crime e um dos acusados fugiu sendo alcançado cerca de três quarteirões adiante. Informalmente, os três indivíduos confessaram que estavam lá para pegar a vítima a mando de "Gordinho". O depoente narrou que casos semelhantes estão ocorrendo na cidade de Guarujá, envolvendo moradores da Conceiçãozinha, e essa "quadrilha do Pix" é liderada por indivíduo conhecido por "Gordinho". O depoente, ao examinar a foto de fls. 06 que lhe foi apresentada, disse que quem estava com o simulacro era o acusado de nº 1 (David), e o acusado de nº 3 foi o que correu e acabou sendo alcançado pelo depoente. Em sede policial, o depoente afirmou que foi encontrada porção de maconha para uso pessoal com o acusado David. Em juízo, não se recordou do nome do acusado, mas tem lembrança de que um deles portava maconha para consumo pessoal (fls. 388).

Ressalte-se que os depoimentos dos policiais civis merecem credibilidade, pois não se pode presumir a intenção de incriminar falsamente os acusados da prática de delito, ainda mais quando seus depoimentos são seguros e precisos. Ademais, não restou comprovada qualquer razão concreta de suspeição, presumindo-se a veracidade dos depoimentos, que serão analisados em conjunto com os demais elementos de prova existentes nos autos.

A propósito, vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça que:

"[...] o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova [...]" (STJ, HC 471082 / SP, Rel. Ministro Felix Fischer, j. 23/10/2018, DJe. 30/10/2018).

"[...] os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa [...]" (STJ, HC 496335 / SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, j. 02/04/2019, DJe 08/04/2019).

Como se vê, as provas produzidas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, tornam evidentes a materialidade e a autoria delitiva dos réus, de forma inequívoca.

A vítima discorreu com precisão sobre a conduta criminosa praticada pelos réus, bem

como a grave ameaça que sofreu, exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo, para a subtração de seus bens. O ofendido, em sede policial, reconheceu os três réus, sem sombra de dúvidas, como sendo os autores da tentativa de roubo de seus bens. Identificou o réu David como o indivíduo que portava o simulacro de pistola, o réu Cleverson como um dos três indivíduos que participaram da tentativa de roubo e o réu Igor como o indivíduo que tentou fugir do local dos fatos. E as declarações da vítima foram corroboradas pelos depoimentos dos policiais civis que atenderam a ocorrência, os quais presenciaram a chegada dos acusados, que se dirigiram na direção da vítima, e o réu David iniciou a execução do crime sacando o simulacro de arma de fogo contra a vítima. Até então, não se sabia que se tratava de simulacro. Nesse momento, os agentes públicos intervieram para impedimento da consumação do crime e abordaram os acusados. O réu Igor tentou fugir, mas foi alcançado pelo policial Jairo poucos metros à frente do local dos fatos. Com o réu David também foi encontrada uma porção de maconha para uso pessoal. Os três acusados foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia. Ressalto que os depoimentos das testemunhas de defesa não foram capazes de afastar a conduta típica praticada pelos réus.

Michele da Silva Lins, em seu depoimento judicial, relatou que o réu Igor foi seu professor particular de artes marciais, e também de seu filho. Desconhece qualquer fato que possa desabonar a conduta social e profissional do acusado, que inclusive ministra aulas para crianças, prepara atletas para a disputa de campeonatos, e sempre pregando respeito e honra para com o próximo. Não presenciou os fatos e causou-lhe grande surpresa a notícia da prisão de Igor (fls. 388).

Yasmin Francis Mordes dos Santos, em juízo, relatou que já foi aluna de artes marciais do réu Igor e desconhece qualquer fato que possa desabonar a conduta social e profissional do acusado. Não presenciou os fatos, e pelo que conhece de Igor, jamais poderia imaginar a hipótese de envolvimento de seu professor com condutas ilícitas (fls. 388).

Stefany dos Santos da Cruz, em seu depoimento judicial, relatou que conhece Igor por intermédio de amigos comuns, Igor é professor de artes marciais, ministrando aulas em academias do Perequê e da Enseada, e também aulas particulares. Não presenciou os fatos e nada conhece, que possa desabonar a conduta social e profissional de Igor (fls. 388).

Pois bem, as testemunhas de defesa não presenciaram os fatos e apenas informaram sobre a idoneidade do réu Igor, de forma que devem prevalecer as declarações da vítima e os depoimentos dos policiais que presenciaram os fatos.

Logo, as provas produzidas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, tornam evidentes a materialidade e a autoria delitiva dos réus, de forma inequívoca.

No que tange à causa de aumento do concurso de pessoas, também restou comprovada nos autos.

Considerando as declarações da vítima e os depoimentos dos policiais civis, inequívoco que os réus agiram em conluio e mediante prévio ajuste, estando demonstrado o concurso de agentes e a divisão de tarefas entre os praticantes do crime de roubo tentado descrito na denúncia.

Importante destacar que, se a palavra da vítima tem valor para comprovação de autoria, com muito mais razão para confirmar a causa de aumento, quando sua declaração é clara e segura, como no presente caso.

O crime de roubo restou configurado na sua forma tentada, pois os policiais civis intervieram em favor da vítima no início da execução do crime, para impedirem a subtração de seus bens, e os acusados não obtiveram êxito na empreitada criminosa. Logo, os réus não conseguiram subtrair bens da vítima por circunstâncias alheias a suas vontades.

Portanto, as provas demonstraram que os réus praticaram o crime de roubo tentado narrado na denúncia, em conluio e unidade de desígnios entre si e outro indivíduo não identificado, mediante o emprego de grave ameaça contra a vítima - exercida com o emprego de simulacro de pistola - não consumando o delito por razões alheias a suas vontades. E o réu David trazia consigo porção de maconha para uso pessoal. Logo, não se pode pretender a desclassificação para o crime de furto tentado, tendo

em vista que os fatos foram praticados mediante ameaça exercida pelo simulacro de arma de fogo.

Nesse sentido, a jurisprudência:

"Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo (simulacro). Crime praticado em face de estabelecimento comercial (joalheria). Acusados e comparsa não identificado ingressaram na joalheria e, munidos com um simulacro de arma de fogo, renderam três vítimas e subtraíram diversas peças do local, evadindo-se em poder dos bens. Os acusados foram detidos no dia seguinte à empreitada criminosa em poder de parte dos bens subtraídos e do simulacro de arma de fogo. Insurgência defensiva. Pleito de desclassificação da conduta para o crime de furto. Impossibilidade. Grave ameaça devidamente comprovada, consistente em anunciar o roubo portando um simulacro de arma de fogo, subjugando, assim, as vítimas e exigindo delas, inclusive, auxílio para a separação dos bens. No entanto, de rigor a exclusão da causa de aumento referente à arma de fogo, [...] dada a absoluta ausência de poder vulnerante, prestando-se o simulacro, apenas e tão-somente, à configuração da grave ameaça. [...] Dessa forma, sobrevém a condenação dos réus por infração ao artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal [...]" (TJ-SP - APR: 15081096620198260032-SP, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 05/10/2021, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/10/2021).

Comprovadas materialidade e autoria, definidas as condutas dos acusados, passo à dosimetria das penas.

Em relação aos réus Igor Gonçalves de Abreu de Jesus e Cleverson Nascimento de Almeida Júnior:

Na primeira fase, considerando os critérios do artigo 59 do Código Penal, tratando-se de réus primários (fls. 76, 79/80, 72, 77/78), fixo a pena-base no mínimo legal: 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Deixo de proceder a outros aumentos, tendo em vista que os réus agiram com dolo normal à espécie e as circunstâncias e consequências do delito não extrapolaram os limites inerentes ao próprio tipo penal.

Na segunda fase, a pena permanece inalterada, pois ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes para serem consideradas.

Na terceira fase, presente a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas (artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal), elevo a pena em 1/3, perfazendo 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Nos termos do artigo 14, inciso II, do Código Penal, atentando-se ao "iter criminis" percorrido pelos acusados - os quais foram abordados pelos policiais civis e impedidos de praticarem o crime de roubo logo no início da execução - diminuo em 2/3 a pena aplicada. Analisando a dinâmica dos fatos, conclui-se que os réus Igor, Cleverson e David se aproximaram da vítima e no momento em que o réu David iniciou a execução do crime, sacando o simulacro de arma de fogo para ameaçar a vítima - ressaltando-se que até então não se sabia que se tratava de simulacro - os policiais civis intervieram e evitaram a consumação do delito. Aplicando a diminuição de 2/3, a pena perfaz 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 05 (cinco) dias-multa.

Em relação ao réu David dos Santos Machado, para o crime de roubo:

Na primeira fase, considerando os critérios do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal: 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Deixo de proceder a outros aumentos, tendo em vista que o réu agiu com dolo normal à espécie e as circunstâncias e consequências do delito não extrapolaram os limites inerentes ao próprio tipo penal.

Na segunda fase, não obstante o réu seja reincidente (fls. 73/74, 81/83), deixo de aplicar a circunstância agravante da reincidência ante a presença da circunstância atenuante da confissão, ficando compensadas as circunstâncias.

Justifica-se.

Embora o artigo 67 do Código Penal determine a preponderância à reincidência, o certo é que, a confissão é favorável ao réu e diz respeito à personalidade do agente, tanto quanto a reincidência, não havendo nenhuma ilegalidade em sua



compensação em sede de individualização da pena. Assim, a agravante da reincidência deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, tendo em vista a preponderância de ambas as circunstâncias consideradas.

Aliás, nesse sentido, tem se posicionado a jurisprudência:

"[...] 4. A Terceira Seção desta Corte, no exame do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, decidiu que, observadas as especificidades do caso concreto, 'é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência', uma vez que são igualmente preponderantes." (STJ, HC 605603 / ES, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23/03/2021, Dje 29/03/2021).

Confira-se, ainda:

"[...] IV - Resulta imperativo considerar o entendimento firmado no julgamento do HC n. 365.963/SP (de minha relatoria, Dje 23/11/2017), oportunidade em que a Terceira Seção desta Corte pacificou entendimento no sentido de que a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não foi ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito." (STJ, HC 617049 / SP, Quinta Turma, Rel. Felix Fischer, j. 17/11/2020, Dje. 23/11/2020).

Ainda nesse sentido:

"[...] Incabível, por outro lado, a preponderância da agravante sobre a atenuante como pretende a acusação. Não me parece - respeitadas as opiniões divergentes - que a reincidência deva preponderar sobre a confissão: o art. 67, do Código Penal, manda que se considerem, preponderantemente, as circunstâncias 'que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência'; ora, a personalidade do agente há de ser julgada, entre outros fatores, pela confissão, por exemplo, razão por que deve esta compensar o aumento que seria devido pela reincidência." (TJSP, Apelação Criminal nº 1500131-07.2019.8.26.0592, 10ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Francisco Bruno, j. 19/05/2021).

Ainda, na segunda fase, deixo de aplicar a atenuante da menoridade relativa do réu David, uma vez que a atenuante não pode levar a pena aquém do mínimo legal

Na terceira fase, presente a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas (artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal), elevo a pena em 1/3, perfazendo 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Nos termos do artigo 14, inciso II, do Código Penal, atentando-se ao "iter criminis" percorrido pelos acusados - os quais foram abordados pelos policiais civis e impedidos de praticarem o crime de roubo logo no início da execução - diminuo em 2/3 a pena aplicada. Analisando a dinâmica dos fatos, conclui-se que os réus Igor, Cleverson e David se aproximaram da vítima e no momento em que o réu David iniciou a execução do crime, sacando o simulacro de arma de fogo para ameaçar a vítima - ressaltando-se que até então não se sabia que se tratava de simulacro - os policiais civis intervieram e evitaram a consumação do delito. Aplicando a diminuição de 2/3, a pena perfaz 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 05 (cinco) dias-multa.

Em relação ao réu David dos Santos Machado, para o crime de porte de droga para consumo pessoal:

Considerando as circunstâncias judiciais constantes no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena de forma definitiva, à mingua de outras circunstâncias que a aumentem ou diminuam, em 02 (dois) meses de prestação de serviços à comunidade.

Torno definitivas as penas aplicadas.

Considerando o concurso material, somando-se as penas, a pena perfaz em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 05 (cinco) dias-multa e em 02 (dois) meses de prestação de serviços à comunidade.

Ausentes dados acerca da situação econômica dos réus, fixo o valor do dia multa em seu patamar mínimo, nos termos do artigo 49, parágrafo 1º, do Código Penal, sendo que o valor do dia multa deverá ser objeto de correção monetária, na forma do artigo 49, parágrafo 2º, do Código Penal.

No caso dos autos, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, por entender que se trata do regime prisional que se amolda às condutas dos réus.

Ainda, considerando que se trata de delito praticado com grave ameaça, não estão presentes os requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, tampouco para a suspensão condicional da pena, nos termos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Considerando a pena aplicada e o tempo da prisão provisória dos réus Igor e Cleverson, sem antecedentes e primários (presos de 25 de março de 2022 até a presente data) e que devem cumprir 25% da pena para fins de progressão de regime (artigo 112, inciso III, da Lei de Execução Penal), verifica-se que os réus não fazem jus à progressão para o regime aberto.

Por fim, considerando que o réu David é reincidente - apresentando condenação recente e definitiva pelo crime de tráfico de drogas, fls. 73/74 - eventual progressão de regime será apreciada necessariamente pelo juízo da execução. Destaco que as alterações trazidas pela Lei nº 12.736/2012, que acrescentou o parágrafo 2º ao artigo 387 do Código de Processo Penal, não revogaram os dispositivos da Lei de Execução Penal, que devem também ser considerados para a progressão de regime.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move contra David dos Santos Machado, Igor Gonçalves de Abreu de Jesus e Cleverson Nascimento de Almeida Júnior, para o fim de CONDENÁ-LOS à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 05 (cinco) dias-multa, no valor unitário do mínimo legal, por incursos nas sanções do artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. E também para o fim de CONDENAR David dos Santos Machado à pena de 02 (dois) meses de prestação de serviços à comunidade, por incurso nas sanções do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Os acusados não poderão apelar em liberdade. De fato, presos em flagrante, assim permaneceram durante toda a instrução e, agora, com a presente decisão, mais razão ainda para permanecerem custodiados. Trata-se do grave crime de roubo tentado, em concurso de agentes, e se os réus aguardarem o direito de recorrer em liberdade poderão não ser encontrados para a aplicação da presente decisão, tornando-a inócua. Ainda, em liberdade, poderão reiterar a prática de condutas ilícitas, colocando em risco a ordem pública.

Recomendem-se os réus na prisão em que se encontrarem.

Decreto o perdimento dos três telefones celulares apreendidos (fl. 32, lacre 002485), pois se trata de instrumentos utilizados para a prática do crime, bem como o perdimento do valor em espécie apreendido com o réu David (R\$ 42,00 - quarenta e dois reais, fls. 28, 32), em favor da União. Após o trânsito em julgado, oficie-se à autoridade policial e ao Banco do Brasil comunicando.

Oficie-se desde já à autoridade policial competente requisitando as providências necessárias para a destruição do simulacro apreendido (fls. 32/33 - um simulacro de pistola na cor preta, lacre 002486).

Nos termos da Lei nº 11.343/2006, após o trânsito em julgado, oficie-se à autoridade policial competente requisitando a destruição da porção de droga reservada para eventual contraprova.

No que tange as custas processuais, foi concedido o benefício da gratuidade da Justiça aos três réus, às fls. 167, 206 e 277.

P.I.C.

Guaruja, 20 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA